

1501539-98.2022.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... autoridade policial toma conhecimento do tráfico, sendo-lhe inerente o dever de investigar.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501539-98.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501539-98.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2170293/2022 - 03º D.P. AMERICANA, 25723772 - 03º D.P.

AMERICANA, 2170293 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAN MICHAEL DE CAMPOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

KAUAN MICHAEL DE CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006, porque, na data e local descritos na denúncia, trazia consigo e guardava, para o fim de consumo de terceiros, substância entorpecente (24 porções de MACONHA, pesando 38,9 gramas; e 19 porções de COCAÍNA, pesando 2,7 gramas) que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia de fls. 101/102, foi recebida em 23 de agosto de 2022 (fls. 161/163).

O réu foi citado, apresentando defesa (fls. 130/138).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 172/173 e 195/196).

Em seus memoriais (fls. 200/210), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

A Doutora Defensora do réu (fls. 213/223), requereu o reconhecimento das atenuantes, a aplicação do redutor do paragrafo 4º, e a fixação de regime mais brando.

Ante a apresentação de matéria preliminar, os autos retornaram ao Ministério Público para manifestação (fls. 228/229).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A preliminar suscitada pela Doute Defesa deve ser afastada. Com efeito, já é pacífico na jurisprudência a possibilidade do guarda municipal realizar a prisão, porque nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo pode realizar prisão em flagrante. Além disso, o direito à inviolabilidade do domicílio, revisto no artigo 5º, XI da Constituição Federal, possui exceção no próprio artigo, ao ressaltar os casos de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Como se vê, são quatro exceções: uma delas, a determinação judicial, mas neste caso somente durante o dia; as outras três não possuem limitação temporal, podem ser durante o dia ou mesmo durante a noite, basta que estejam ocorrendo naquele momento. Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. 3. (...). 4. Ordem denegada. (HC 129.932/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 01/02/2010)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. INOCORRÊNCIA. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. (...). 2. É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado no caso dos autos, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados

concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que possui outros registros criminais, já tendo sido, inclusive, condenada, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 5. (...). 9. Habeas corpus não conhecido. (HC 549.805/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020)

A presente demanda originou-se de realização de diligência policial de rotina para a verificação de ocorrência e preservação, e não trabalho investigativo por parte dos policiais. A indicação de que o local conhecido pelo tráfico de drogas, e a denúncia de possível prática delituosa, somada a localização de substância entorpecente, além da confissão do réu acerca da traficância, comprovam a legalidade dos atos perpetrados.

Dessa forma, diversamente do sustentado, nenhum abuso, ou nulidade, ocorreu na diligência policial. Tratando-se "de crime permanente, a ensejar sempre prisão em flagrante, não há que se questionar sobre a preexistência, nulidade ou descumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, porque a inviolabilidade domiciliar é princípio que não se compadece, em termos infracionais, com o desvio de finalidade da função da própria casa, conforme se infere do disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal" (JCAT 75/590).

Por fim, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, "proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida; 'coisas achadas ou obtidas por meios criminosos' (art. 240, § 1º, b, do CPP); 'instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos' (art. 240, § 1º, c, do CPP); 'armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso' (art. 240, § 1º, d, do CPP); 'objetos necessários à prova de infração ou à defesa do autuado' (art. 240, § 1º, e, do CPP); 'cartas, abertas ou não, destinadas ao autuado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato' (art. 240, § 1º, f, do CPP); e 'qualquer elemento de convicção' (art. 240, § 1º, h, do CPP)".

A alegação de nulidade por ausência de justa causa para a revista não deve prosperar no presente caso. Conforme delimitado nos autos do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), pelo Superior Tribunal de Justiça, a busca deve ser, "baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência", o que resta presente, posto que os policiais localizaram a substância entorpecente e o réu confirmou o delito.

No mais, a fundada suspeita, considerando, também, que o local é conhecido pelo tráfico, restou comprovada pela apreensão de drogas. Desta forma, a conduta dos policiais restou fundada na justa causa, em especial pela necessidade de imediata cessação da conduta criminosa, não se tratando de medida ilegal e abusiva.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes se encontra comprovada pelos laudos de fls. 69/71.

É notório o perigo à incolumidade pública causado pela droga conhecida como cocaína, de alto poder viciante e que causa dependência física e psíquica, demonstrando estar plenamente caracterizada a prática delitiva.

De acordo com a doutrina:

"É tão grave a nocividade dessa droga que, mesmo depois da cura pela desintoxicação, o viciado não se recupera das lesões mais graves do sistema nervoso. Tem estados depressivos e de angústia, alucinações visuais e tácteis, delírios de perseguição e complexo de culpa. Envelhece muito precocemente, e a morte é quase sempre por perturbações cardíacas" (DE FRANÇA, GENIVAL VELOSO. Medicina Legal. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, p.308).

A esse respeito, a matéria publicada no conceituado jornal "Folha de São Paulo"; em 30 de dezembro de 1994:

"Cocaína é maior causa de infarto em jovens

A cocaína é responsável por quase todos os infartos do miocárdio em jovens com menos de 30 anos. A constatação é da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) que lança na próxima semana uma campanha nacional de informação.

O objetivo é esclarecer as pessoas sobre as doenças do coração e o que se deve fazer para evitá-las. Entre os jovens, o uso da cocaína é o que mais preocupa a SBC.

"Eles precisam saber que a cocaína tem efeitos mortais no organismo", diz Claudio Buarque Benchimol, 47, secretário-geral da SBC. "Quase todos os jovens que chegam com infarto nos hospitais fizeram uso de cocaína", afirma.

É o que acontece no Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas, umas das mais importantes portas de entrada de vítimas de infarto em São Paulo.

O cardiologista Marcello Barduco, do pronto-socorro do Incor, confirma que entre os jovens a causa do infarto está quase sempre associada ao uso de cocaína.

O hospital registra uma média de um a três casos de infartos em jovens por mês. A cada 24 horas, o Incor recebe uma média de cinco vítimas de infarto, idosos na grande maioria.

Não há estudos sobre os riscos nem estatísticas sobre casos de infarto por droga entre jovens. De acordo com Benchimol, o número de mortes do coração provocado por cocaína pode estar subnotificado por interferência da família. Ou mesmo pela dificuldade em se apontar a droga como causa.

De todo modo, o número de jovens que morrem por infarto é pequeno. Segundo dados da Fundação Seade, apenas 33 jovens entre 15 e 29 anos morreram de infarto do miocárdio na cidade de São Paulo no ano passado. Para se ter uma idéia, nesse mesmo período, 2.298 jovens dessa faixa de idade foram assassinados com armas de fogo e outras armas. Outros 561 morreram no trânsito.

A preocupação da SBC é com o aumento do uso da cocaína registrado nos últimos anos.

"O número de usuários dessa droga vem aumentando no mundo todo", diz Benchimol.

Pesquisa feita entre estudantes de 1º e 2º grau de dez capitais brasileiras mostra que 1,2% deles já experimentou cocaína. Cinco anos atrás, apenas 0,7% dos estudantes tinham usado a droga uma vez. A pesquisa foi feita pelo Cebrid, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas.

O perigo da cocaína é apenas um dos itens da campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Os médicos pretendem informar em linguagem simples como se iniciam as doenças do coração e o que pode agravá-las ou fazer com que regridam.

A hipertensão arterial e o fumo, por exemplo, são fatores de risco para um infarto. Alimentação correta, pouco estresse e exercícios físicos ajudam a manter o coração mais saudável."

E ainda:

"A quantidade necessária para provocar uma overdose varia de uma pessoa para outra, e a dose fatal vai de 0,2 a 1,5 grama de cocaína pura. A possibilidade de overdose, entretanto, é maior quando a droga é injetada diretamente na corrente sanguínea. O efeito da cocaína pode levar a um aumento de excitabilidade, ansiedade, elevação da pressão sanguínea, náusea e até mesmo alucinações.

(...)

A cocaína é a droga que mais rapidamente devasta o usuário. Bastam alguns meses ou mesmo semanas para que ela cause um emagrecimento profundo, insônia, sangramento do nariz e coriza persistente, lesão da mucosa nasal e tecidos nasais, podendo inclusive causar perfuração do septo (12). Doses elevadas consumidas regularmente também causam palidez, suor frio, desmaios, convulsões e parada respiratória". (S.H. Cardoso e R.M.E. Sabbatini; Revista Cérebro & Mente 3(8), jan/mar 1999).

No mais, não há dúvida que a droga "cannabis sativa", popularmente conhecida por "maconha" causa grave dano à incolumidade pública.

Nesse sentido, o editorial do jornal Folha de São Paulo do dia 21 de fevereiro de 2000:

MACONHA E DEPENDÊNCIA

Observa-se, em São Paulo, um aumento no número de casos de pessoas que procuram ajuda médica devido a complicações relacionadas à maconha. Trata-se de uma tendência ainda não quantificada em termos científicos, mas algumas clínicas registraram um acréscimo de 20% na demanda por esse atendimento. A Universidade Federal de São Paulo inaugurou, há três semanas, um ambulatório para esses pacientes. A maconha ainda está longe de constituir um problema de saúde pública, pelo menos um problema tão grande como os 10% de dependentes de álcool na população ou os inúmeros viciados em cocaína e crack. Isso, obviamente, não é razão para fechar os olhos para a questão.

Esse fenômeno com a maconha se explica, em parte, devido a uma mudança de paradigma na psiquiatria. Até meados dos anos 80, a dependência em relação a uma droga era avaliada basicamente pela tolerância (a necessidade de usar cada vez mais para obter o mesmo efeito) e pelo nível dos sintomas de abstinência (os efeitos físicos desagradáveis provocados pela retirada da droga). Em 87, a Associação Americana de Psiquiatria decidiu incluir também critérios psicossociais que indicassem um envolvimento sério do indivíduo com a substância para determinar se ele era ou não um dependente. Trocando em miúdos, pode ser considerado dependente todo aquele cujo envolvimento com alguma droga lhe provoca problemas sociais. Essa nova visão faz mais sentido. Afinal, o ser humano carrega em sua herança genética ou cultural uma fabulosa capacidade de ligar-se de forma patológica a determinados comportamentos, com ou sem drogas. É o caso, por exemplo, dos jogadores compulsivos. Aí, o próprio cérebro pode estar produzindo substâncias que o levam ao vício. São os chamados opióides endógenos. A literatura médica também registra episódios de dependências mais exóticos, como a de comer cenouras. Não se sabe ao certo se o beta-caroteno encontrado nesse vegetal tem potencial aditivo ou se o vício teria explicação em ritualizações. De todo modo, para a imensa maioria das pessoas, a cenoura é apenas um alimento, e saudável. Tudo está na forma como o indivíduo se relaciona com a droga, que pode ser patológica ou não, dependendo de inúmeras variáveis relacionadas à própria substância e à personalidade do usuário. O fato é que não faz mais tanto sentido falar em drogas leves. Droga é droga e muitas vezes tem consequências desastrosas. (os grifos são meus).

A autoria, relativo ao tráfico, é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra *Do Flagrante Delito*, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados

nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, os guardas municipais informaram que se encontravam em patrulhamento e receberam uma denúncia de populares acerca da ocorrência de tráfico em um cruzamento, onde um indivíduo teria escondido as drogas, sendo que informaram, ainda, as características da pessoa. Continuaram o patrulhamento e, no local indicado, embaixo de uma pedra, localizaram a substância entorpecente (maconha). Narraram que na praça próxima, conhecida pelo tráfico de drogas, encontraram um indivíduo com as mesmas características. Indagado, este confirmou a propriedade da droga encontrada, e indicou o local onde mais porções estariam escondidas, sendo localizadas próximas de uma árvore (cocaína). Por fim, declararam que o réu confirmou a prática do tráfico, alegando que estava passando por necessidades.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas” (Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça – art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente - (...). (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de enfrentamento das alegações defensivas e falsidade dos depoimentos judiciais dos policiais militares – Inocorrência – Decisão motivada –

Desnecessidade de menção pormenorizada sobre cada um dos argumentos apresentados - Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para macular a prova colhida - Policiais que não teriam qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados - (...) - Sentença mantida - Recurso não provido (Apelação nº 1501078-10.2017.8.26.0567, da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: SALLES ABREU, Data: 011 de agosto de 2018)

APELAÇÃO - tráfico de drogas qualificado. Apelante que nega o delito. Testemunha de defesa sem credibilidade por contradições e inconsistência fática de sua fala, inclusive com determinação de processo para averiguar o falso testemunho. Testemunhas de acusação coesas quanto ao essencial. Pequeno desvio é derivado da condição de abordagem. Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e impugnação a ele deve ser específica, determinada e não genérica pela origem. (...). (TJSP; Apelação Criminal 1500462-48.2018.8.26.0228; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. 63 (b) - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. RJDTACRIM VOLUME 6 PÁG.78 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-JOSÉ HABICE.

Inclusive, julgando Apelação Criminal oriunda deste juízo, assim decidiu a 14ª Câmara do 7º Grupo da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Ressalte-se que, eventuais discrepâncias entre os depoimentos não geram insegurança acerca dos fatos, pois oriundas das imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada, sendo, sim, importante, verificar se, embora divergentes em detalhes mínimos, concordam os testemunhos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias mais decisivas dos fatos" (Apelação Criminal nº 00976517.3/3-0000-000, Rel. DES. FERNANDO MATALLO, 24.05.2007).

Não procedem as alegações da defesa quanto à divergência/imprestabilidade dos depoimentos dos policiais. O depoimento dessas testemunhas tem o mesmo valor que o de qualquer outra, ainda mais quando a mera alegação de sua imprestabilidade vem desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso:

Tráfico de entorpecentes - Agente surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 21,5 gramas de cocaína, em pó - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Tráfico de entorpecentes - Dolo de traficar - Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) - Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes. (TJSP; Apelação Criminal 0003382-85.2013.8.26.0538; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento:

13/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

PROVA - Depoimento de Policiais - Valor:70(a) - Os testemunhos de Policiais possuem validade jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis, inexistindo qualquer vedação legal, sendo certo que, a simples condição de Policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. (Apelação nº 1.179.625/0, Julgado em 22/02/2.000, 14ª Câmara, Relator: Oldemar Azevedo, RJTACRIM 47/274)

No mais, não há qualquer irregularidade pelo fato de investigação se ter iniciado por denúncia anônima. É irrelevante o meio pelo qual autoridade policial toma conhecimento do tráfico, sendo-lhe inerente o dever de investigar. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protraí no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que, após chegada ao local para averiguação de "denúncia anônima" recebida acerca da chegada de um carregamento de drogas na residência, o corréu ALEX percebeu a presença da guarnição e corréu para dentro do imóvel, momento em que os policiais decidiram ingressar na residência e flagraram os corréus VILSON e ARIZON descarregando tabletes de pasta-base de cocaína de uma Kombi semidesmontada, tendo o paciente e o corréu OSVALDO sido detidos no interior do domicílio. Realizada as buscas pessoais, veiculares e as demais diligências, a atividade policial logrou em apreender 107 tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 95,245Kg. De sorte que eram fundadas as razões para a atuação policial. Desse modo, na presença de elementos suficientes a autorizar a medida estatal, não há como acolher a alegada ilicitude da prova para absolver o paciente pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 569.437/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020)

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento do tóxico apreendido evidencia a destinação de tráfico.

É certo que a simples apreensão de grande quantidade não é bastante para a caracterização do delito de tráfico. Todavia, a quantidade expressiva, somada

variedade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente, é forte indício do comércio ilícito, que aliada às demais circunstâncias servem para a certeza necessária para a prolação de um decreto condenatório, razão pela qual é impossível, ainda, a desclassificação para o consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/06). Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico ilícito de drogas. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Depoimentos dos policiais civis coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório. Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Incabível. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos narcóticos, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas - A condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 - Redução da pena conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Inadequada. A quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos representam perigo maior, atingindo incontáveis usuários, além de apresentarem alto risco à saúde pública com a colocação de tamanha quantidade de entorpecentes na rua - Ademais, as circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação habitual do apelante à prática do crime de tráfico ilícito de drogas, não se tratando de mero traficante eventual, que, por descuido, envolveu-se com a traficância momentaneamente - (...) - Pena e regime mantidos Recurso desprovido. (Apelação Criminal nº 0002456-25.2017.8.26.0616, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Presença de indícios tipificadores do delito - Apreensão de grande quantidade de entorpecente - Excessivo poder de compra que não se adequa à condição simples do réu - Aplicação dos artigos 12 e 37 da lei 6368/76 - Recurso não provido. (Relator: Gentil Leite - Apelação Criminal n. 161.748-3 - Campinas - 01.09.94)

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Ré surpreendida na posse expressiva quantidade de maconha e uma porção de cocaína - Quantidade e natureza da droga que evidencia o objetivo de mercancia - Recurso não provido. (Relator: Segurado Braz - Apelação Criminal n. 161.094-3 - São José do Rio Preto - 16.05.94)

Cumprir destacar que o local onde o réu foi preso é conhecido como intenso ponto de tráfico de drogas.

Em juízo acusado Kauan confirmou a prática do delito. Disse que estava passando por dificuldades financeiras e desempregado, e acabou por aceitar praticar o delito. Confirmou que toda a droga encontrada estava em sua posse, e iria vender para o contratante.

Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

“Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: “A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui

seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003). (AC 2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

De acordo com a Doutrina:

“É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem” (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, pag. 378/379).

Desta forma, a quantidade e variedade de droga, a forma de acondicionamento, os objetos e/ou o valor em dinheiro de origem não elucidada permitem a segura conclusão de que o entorpecente apreendido era destinado ao tráfico.

Pelas provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar as penas.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, tendo em vista que a extrema nocividade da cocaína, exigindo especial rigor no combate ao seu tráfico, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal, pela necessidade de impor ao traficante pena de severidade correspondente ao elevado risco que o comércio dessa nefanda substância acarreta à saúde pública.

O réu agiu reprovadamente com vontade livre e consciente, dirigida à prática de condutas que representam tráfico de cocaína, droga especialmente perigosa, colocando em grave perigo a saúde pública, acrescendo como circunstância a quantidade expressiva da droga, tendo como motivo o propósito de locupletamento, vale dizer, ganho fácil e espúrio.

Com efeito, segundo Damásio:

“O novo sistema penal prevê duas fases na aplicação da pena. Num primeiro momento, com fundamento no princípio da pena retributiva, fixa sua qualidade e quantidade, elaborando um juízo sobre o passado (juízo de culpabilidade), atendendo à gravidade objetiva do delito, antecedentes e personalidade do agente, sua conduta social anterior, motivos determinantes do fato e suas consequências.” (Damásio Evangelista de Jesus, “Direito Penal”, Parte Geral, 1 volume, 19ª Edição, Saraiva, 1995, p. 509)

Havendo uma graduação de penas, é evidente que a pena mínima, deve ser aplicada, por exemplo, àqueles que comercializam pequena quantidade de “maconha”, tóxico muito menos grave e nocivo que a cocaína, que envolve interesses de grupos altamente perigosos, que para a sua difusão e fabricação se organizam freqüentemente em quadrilhas, patrocinando “chacinas”, segundo diariamente noticiado nos jornais. Destarte é indiscutível que a cocaína apresenta um perigo muito maior, uma maior potencialidade de dano social. Como dito acima, a cocaína freqüentemente leva à morte, além de ser porta para outros tipos de tóxicos mais graves, como a heroína, por exemplo.

A propósito, julgando feito em trâmite por este juízo, assim decidiu a Egrégia 11ª Câmara Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo relator foi o Desembargador Di Rissio Barbosa, do seguinte teor:

Comércio Clandestino de entorpecente. Pena. Exacerbação decorrente da natureza da droga, "crack", cujos efeitos são mais graves que outras drogas. Não é só admissível a exacerbação, como também recomendável por diferenciar situações díspares. (Apelação 455.718.3/1-00, 8 de junho de 2005).

Da brilhante decisão, destaco o seguinte trecho:

"...o aumento decorrente do tipo de droga, de extrema conseqüência, foi adoção que todos os Magistrados deveriam ter em mente ao calcular a pena; realmente, não se pode deferir a mesma repressão aos que se envolvem com drogas consideradas leves, pelas conseqüências que determinam, e outras consideradas pesadas, aqui com maior desprezo ao infeliz semelhante usuário".

Além disso, existe o imperativo legal do artigo 42 da Lei 11.343/2006, segundo o qual a quantidade e natureza da droga devem preponderar sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal no momento de fixação da pena base. Segundo o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE NA NATUREZA E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 1,956 KG DE COCAÍNA. LEGALIDADE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTUM DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO ÓRGÃO JULGADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 17/10/2019) e que "[i]nexiste um critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio [...]" (HC 448.085/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) 2. No caso, a majoração da pena-base em 2 (dois) anos está suficientemente fundamentada, pois as vetoriais previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 foram sopesadas negativamente em razão da apreensão de 1,956 kg (um quilograma e novecentos e cinquenta e seis gramas) de "cocaína". 3. O quantum de majoração adotado não se mostra desarrazoado ou desproporcional, especialmente quando considerado o largo intervalo existente entre as penas mínima e máxima aplicáveis ao delito (de 5 a 15 anos de reclusão), bem como a natureza e elevada quantidade da droga apreendida. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 536.692/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. MODIFICAÇÃO DE REGIME. PLEITO PREJUDICADO, ANTE A MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA. ADEMAIS, PENA SUPERIOR A 7 ANOS E PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É cediço que, quanto à exasperação da pena-base no crime de tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, verifico que a pena-base foi exasperada em razão da variedade/quantidade das drogas (48,759kg de cocaína e 1,011kg de crack), fundamentos idôneos para majorar a pena-base e recrudescer o regime prisional. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no HC 505.140/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA. ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente lastreada na quantidade e natureza do entorpecente encontrado em poder do réu - pasta-base de cocaína, de alto poder deletério -, nos termos do art. 42 da Lei n.

11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea. 2. Agravo desprovido. (AgRg no REsp 1793804/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

Assim sendo, fixo a pena de seis anos de reclusão e seiscentos dias multa, para o delito de tráfico de entorpecentes.

Na segunda fase, diante das circunstâncias atenuantes (art. 65, inc. I, do CP e art. 65, inc. III, "d", do CP), reduzo a pena, retornando-a ao patamar mínimo, ou seja, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Tendo em vista que o réu é tecnicamente primário, no entanto, levando em conta a quantidade de drogas, a existência de atos infracionais envolvendo substância entorpecente (fls. 237/244) e outros processos em andamento (fls. 30), nos termos do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, diminuo a pena no patamar intermediário da 1/2 (metade), totalizando em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Tema 1139, do STJ: É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06. (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR)

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime prisional deverá ser o aberto, nos termos do art. 33, §2º, letra "c" do CP.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao providenciar o cancelamento de sua Súmula nº 512, assentou que o tráfico de entorpecente, em sua forma privilegiada, não tem natureza hedionda.

Nessa linha, consta o julgamento do HC 118.533 do Supremo Tribunal Federal, o qual decidiu pelo afastamento da hediondez do delito de tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO E POR TRÁFICO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA AFASTADA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 23/6/2016, o HC 118.533/MS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, passou a adotar o entendimento de que "o crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda". Posteriormente, a Quinta e a Sexta Turmas do STJ, revendo posição anteriormente adotada, passaram a acompanhar o julgado do STF. Desse modo, a execução penal deve tratar o crime praticado pelo paciente como crime comum, e não como crime de natureza hedionda, para fins de cálculo de possíveis benefícios. Precedentes. 2. Está consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento no "sentido de afastar a reincidência específica em relação ao tráfico privilegiado e o tráfico previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas" (HC n. 471.013/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 16/10/2018). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 547.502/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Ainda, a Resolução nº 5 do Senado, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", inserida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, consagrando o princípio constitucional da individualização da pena. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº.11.343/06.

FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO APLICADA. PEQUENA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PRIMARIEDADE E MONTANTE DA PENA QUE ENSEJAM O REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. - O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/07/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. - Ademais, quanto à hediondez do crime de tráfico privilegiado, deve-se acompanhar a decisão do plenário do STF, no exame do HC n. 118.533/MS, julgado em 23/06/2016, de Rel. da Ministra Cármen Lúcia, na qual se assentou que o crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. - Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. - Ora, tendo em vista o montante de pena aplicada, no caso, e considerando que as circunstâncias fáticas concretas não desbordam do ordinário do tipo - apreensão de apenas 1 porção de cocaína, pesando 2 g, e 7 porções de crack pesando 3 g (fl. 27) - cabível o regime inicialmente aberto de cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal, c/c art. 42, da Lei n. 11.343/2006. - Do mesmo modo, no que tange à possibilidade de substituição da pena, o Supremo Tribunal Federal, em 1º/09/2010, no julgamento do HC n. 97.256/RS, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 4º, do art. 33, e do art. 44, ambos da Lei de Drogas, na parte relativa à proibição da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos aos condenados por tráfico de entorpecentes. - No caso, estabelecida a pena-base no mínimo legal e considerando a primariedade do paciente e a quantidade mínima das drogas apreendidas, também faz jus o acusado à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CP. - Habeas corpus não conhecido. - Ordem concedida, de ofício, para readequar o regime prisional inicial do paciente para a modalidade aberta e substituir a pena corporal por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juiz singular. (HC 459.796/SP, Rel. Ministro REYNALDO OARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 08/04/2019)

Desse modo, cabe ao Julgador verificar a possibilidade de aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu KAUAN MICHAEL DE CAMPOS, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixado no piso, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006.

Nos termos dos artigos 43 e seguintes, do Código Penal, em especial os incisos I e IV, do art. 43, converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, na forma de prestação de serviços à comunidade, por igual período ao da pena privativa de liberdade, a ser definida pelo Juízo das Execuções, e em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade filantrópica do Município.

Ainda, nos termos do que dispõe o artigo 63 da Lei 11.343/2006 determino a perda dos bens e valores apreendidos, em favor da União, devendo se proceder consoante os parágrafos do mencionado artigo após o trânsito em julgado da presente sentença.

Considerando o regime fixado, concedo-lhe os benefícios da LIBERDADE PROVISÓRIA.

Expeça-se alvará de soltura clausulado. Desta forma, o réu poderá apelar em liberdade.

Por fim, considerando a concessão da gratuidade da justiça (fls. 163), presumindo-se a insuficiência de recursos, isento-os das custas.
P.I.C.

Americana, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA